



Corte d'Appello di Milano

Sezione prima civile

composta dai Magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente
dr. Maria Elena Catalano	Consigliere rel.
dr. Silvia Brat	Consigliere

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1677/2018** promossa da:

GI. *Pt_1* (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI MARCO LUIGI
elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN BABILA, 4/A 20122 MILANO presso il difensore avv.
ANTONIOLI MARCO LUIGI

APPELLANTE

CP_1 , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e dell'avv.
TAVANO ANNA (*C.F._1*) VIA VIQUARTERIO, 1 20090 PIEVE EMANUELE;
Parte_2 *C.F._2* VIA GUASTALLA, 6 20122 MILANO,
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore
avv. MANDARANO ANTONELLO

APPELLATO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 14.11.2018, la Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, premesso che:

- con provvedimento in data 31 Ottobre 2001 p.g 151187.400/2000 sub 5, il Comune di Milano autorizzava *Parte_3* titolare di un'azienda di bar pasticceria (esercitata sotto l'insegna *Org_1*), sito in Piazza San Babila, all'occupazione dell'area pubblica, per l'estensione pari a 36 mq, previo pagamento dell'importo di lire 13.219.200, quale prima rata del canone concessorio *Org_2*

- con procedimento rg 50514/2003, la *Parte_3* è stata convenuta in giudizio da alcuni proprietari delle unità immobiliari poste negli stabili ai civici n. 4/b e 4/c della Galleria San Babila; i condomini agivano in giudizio chiedendo lo sgombero da parte di *Parte_3* dell'area antistante al bar, sul presupposto dell'appartenenza esclusiva di detta area a loro stessi in forza di una Convenzione urbanistica risalente agli anni '40; in particolare i condomini chiedevano al Tribunale che venisse dichiarata illegittima l'occupazione della porzione di Galleria antistante gli edifici di cui ai civici nn 4/b e 4/c da parte della *Pt_3* [...] a causa dell'indebita installazione da parte di quest'ultima di alcune strutture metalliche, chiedendone, dunque, l'immediata rimozione;
- tale circostanza veniva contestata da *Parte_3* che basava la sua difesa principalmente allegando che sul passaggio dalla stessa occupato gravasse una servitù di diritto pubblico, attestata dal canone di occupazione fino ad allora versato (canone corrisposto dal 2001 al 2008 per complessivi euro 50.546,37); il Tribunale di Milano disponeva la chiamata in causa del *Controparte_2* ex art. 107 c.p.c; nel corso di tale giudizio, il *CP_2* [...] rimaneva contumace;
- il Tribunale di Milano, con sentenza n.7339/2008 passata in giudicato (Cass. 21566/2017), accertata la titolarità del diritto di proprietà delle aree occupate da *Parte_3* in capo ai condomini dei civici 4/b e 4/c di via San Babila, ordinava a *Parte_3* la immediata rimozione degli allestimenti apposti, condannandola al pagamento delle spese processuali; in particolare, il Giudice di prime cure accertava che “ *le due porzioni antistanti i Controparte_3 e 4/C di Milano sono enti condominiali di proprietà degli stessi*” dichiarando, per l'effetto, “*l'illegittimità dell'occupazione da parte della convenuta Parte_3 delle porzioni suddette*”;
- in seguito a tale pronuncia, la *Parte_3* proponeva ai condomini vittoriosi un accordo transattivo, intervenuto in data 16 Maggio 2012, poi effettivamente raggiunto. Nell'accordo veniva previsto quanto segue:
 - i Condomini di Galleria San Babila accordavano a *Parte_3* l'utilizzo dell'area antistante al bar per una superficie di non oltre trenta metri quadri;
 - *Parte_3* si obbligava a versare al condominio *Controparte_4* la somma complessiva € 350.000,00 per spese di manutenzione della Galleria, oltre al rimborso di spese di lite, ammontati complessivamente ad € 58.000,00;

- le parti si impegnavano a far estinguere tutti i giudizi pendenti, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano;
- nel frattempo il Comune di Milano, continuava a riscuotere il pagamento del canone COSAP;
- in conseguenza dei fatti di cui sopra, al fine di far valere le proprie ragioni sia di natura risarcitoria che restitutoria, relativamente alle somme versate a titolo di Cosap per gli anni dal 2001 al 2008, *Parte_3* conveniva in giudizio il *CP_2* di Milano con procedimento sub rg 11038/2013; si costituiva il *CP_2* di Milano eccependo preliminarmente la prescrizione (quinquennale) per i canoni COSAP corrisposti fino al 16.10.2007;
- il procedimento di cui sopra si concludeva con sentenza n. 216 del 2015, con la quale il giudice di prime cure rigettava le domande proposte da *Parte_3* sulla base dell'esistenza sulle aree in questione di una servitù di passaggio;
- nel frattempo, il Comune di Milano, che continuava a riscuotere il pagamento della *Org_2* anche per l'anno 2010, ricorreva al Tribunale di Milano per ottenere da *Pt_3* il pagamento del canone COSAP per gli anni 2009-2010; il Tribunale di Milano emetteva, così, decreto ingiuntivo notificato in data 13.01.2014 nei confronti di *Parte_3* per il mancato pagamento della somma di euro 6.511,00 in relazione al canone COSAP per l'anno 2010;
- con atto di citazione notificato in data 05.02.2014 la *Parte_3* in persona del legale rappresentante pro-tempore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso, convenendo in giudizio il *Controparte_2* e chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione mancando i requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito; si instaurava così il giudizio sub rg 8258/2014;
- il *Controparte_2* resisteva in giudizio nel procedimento nrg 8258/2014 deducendo:
 - che, nel 2000, la società *Pt_3* aveva chiesto al *CP_2* la concessione di suolo pubblico per la posa di tavoli, sedie e paraventi, per mq 36 e che, a corredo di tale richiesta, aveva prodotto il consenso del Condominio Galleria San Babila dei civici n. 4/b e 4/c;
 - che, nel corso del giudizio rg 50514/2003 promosso dai *Controparte_3* dinanzi al Tribunale di Milano, entrambe le parti avevano affermato l'esistenza di una servitù di pubblico passaggio;

- che la concessione di suolo pubblico trovava il suo fondamento nel diritto di uso pubblico sulla Galleria San Babila, della quale il Comune era titolare;

- che i canoni *Org_2* erano stati richiesti in forza del disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 446/1997;

- che la domanda risarcitoria era infondata;

- con sentenza n.14474/2014 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione all'ingiunzione fiscale emessa dal Comune di Milano a carico di *Parte_3* per il mancato pagamento del Cosap per gli anni 2009-2010, relativo all'occupazione di un'area di 36 mq concessa nel 2001 per l'allocatione di 15 tavolini all'aperto;
- entrambe le decisioni (sentenza n.14474/2014 e sentenza n.216/2015), emesse nei rispettivi procedimenti dal Tribunale di Milano, hanno respinto le domande attoree sul sostanziale presupposto della sussistenza di una servitù di pubblico passaggio sulla Galleria S. Babila che –nonostante l'accertata proprietà privata dell'area oggetto di concessione- di per sé legittima la potestà impositiva del tributo da parte del *Controparte_2*, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 446/1997 e del relativo Regolamento comunale;
- avverso dette sentenze (n.216/2015 e n. 14774/2014) venivano proposti da *Parte_3* due separati appelli aventi rispettivamente n.r.g 2315/15 e n.r.g 2693/15, poi riuniti.

In tali procedimenti parte appellante *Parte_3* censurava le due sentenze impugnate sostenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure:

- avrebbe errato laddove (in entrambe le sentenze) ha “*ritenuto l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dell'Amministrazione sulle aree della Galleria San Babila acquisita per usucapione o, comunque, per dicatio ad patriam*” e ciò per non aver tenuto nella dovuta considerazione come preclusivo “*l'accertamento, con efficacia di giudicato, della proprietà privata delle aree intervenuto con la sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano*”, opponibile anche per il *Controparte_2* in quanto parte –volontariamente contumace- del giudizio definito con detta sentenza;

- avrebbe poi errato nel non aver ritenuto illegittima la pretesa impositiva del *CP_2* [...] giacché, quand'anche esistesse la servitù di uso pubblico, questo –a suo dire- non legittimerebbe tale pretesa impositiva in quanto la titolarità di disporre degli spazi antistanti al *Parte_4* stata riconosciuta ai *Controparte_3* (con sentenza n.7339/2008), venendo dunque meno il presupposto impositivo;

- avrebbe errato laddove (con la sentenza n.216/2015) ha ritenuto inammissibile per tardività la domanda di arricchimento senza causa, proposta nella memoria ex art 183 c.p.c. n.1;

- avrebbe errato laddove (con la sentenza n.216/2015) ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione della richiesta di restituzione dei canoni versati per le annualità dal 2001 al 2007;
- avrebbe ancora errato laddove (con la sentenza n.216/2015) ha rigettato l'azione risarcitoria proposta;
- avrebbe infine errato laddove (con la sentenza n.14774/2014) ha ritenuto comunque legittimo il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale da parte del CP_2

In tale giudizio d'appello si costituiva il Controparte_2 chiedendo la conferma della decisione oggetto del giudizio n.2315/15 r.g. e proponendo invece nel giudizio n.2693/15 r.g. appello incidentale per ottenere il pagamento delle spese di lite invece compensate nella relativa decisione impugnata;

- la Corte d'Appello di Milano nei due procedimenti di appello riuniti, sopra citati, con sentenza n. 4081/2017, respingeva l'appello proposto da Par Pt_3 avverso le sentenze del Tribunale di Milano n. 14774/2014 e n. 216/2015, confermando la debenza del canone COSAP al Comune di Milano, relativo alle annualità 2001/2010, così statuendo:

"1. respinge gli appelli proposti in via principale da Par Parte_3 avverso le sentenze n. 14774/2014 e n.216/2015 del Tribunale di Milano;

2. accoglie l'appello incidentale proposto dal Controparte_2 avverso la sentenza n. 216/2015 del Tribunale di Milano e, in riforma della stessa, condanna Parte_3 al pagamento delle spese di quel giudizio in favore del Controparte_2 che liquida in €.12.000 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;

3. condanna l'appellante Parte_3 al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in €.9.000 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;

4. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante Parte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002".

- Il presente giudizio di appello sub rg 1677/2018 ha origine da una serie di ingiunzioni di pagamento emesse dal Controparte_2 verso le quali la Parte_3 ha proposto opposizione.
- In particolare, con atto di citazione notificato il 25 Febbraio 2015, Pt_3 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2014 0430018990000014212 con cui il Comune di

Milano notificava a **Parte_3** l'ingiunzione di pagamento per l'importo di € 6.811,00 per la mancata corresponsione del canone COSAP per l'anno 2011; si costituiva in giudizio il **CP_2** convenuto, al fine di resistere alle domande giudiziali nei suoi confronti proposte, assumendo la debenza del tributo oggetto di contestazione tra le parti;

- con sentenza n. 10066/17, pubblicata il 09.10.2017 e non notificata, il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da **Parte_3** nei confronti del **CP_2** di Milano, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, che condannava **Part Pt_3** al pagamento in favore del **Controparte_2** della somma di Euro 6.811,00, per il pagamento del canone COSAP, in relazione all'anno 2011, dovuto per l'occupazione dello spazio pubblico antistante l'esercizio commerciale **Org_1** [...] sito in **Controparte_4** ;
- secondo il giudice di prime cure, l'occupazione dell'area soggiace al canone COSAP, il **CP_2** di Milano ha dunque correttamente applicato la tariffa, e la domanda giudiziale di **Parte_3** deve essere rigettata;
- il Tribunale adito, che ha deciso nei termini di cui sopra, ha considerato che in base all'art. 63 D. Lvo 25 dicembre 1997, n. 446 e all'art. 2 comma 4 del Regolamento COSAP del Comune di Milano, *“sono soggette al canone in oggetto le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a pubblico passaggio: nel caso di specie, sebbene le aree occupate dall'attrice siano di proprietà dei condomini antistanti, le medesime sarebbero gravate da una servitù di passaggio pubblico, sussistendo i presupposti richiesti dalla giurisprudenza prevalente in tema di dicatio ad patriam, con la conseguente “assunzione da parte del bene di caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale”*;
- tale pronuncia del Tribunale di Milano veniva impugnata da Gi. **Parte_3** con atto di citazione notificato in data 09.04.2018 con cui conveniva in giudizio il **Controparte_2** dinanzi alla Corte d' Appello di Milano, instaurando il presente procedimento sub r.g 1677/2018;
- si costituiva in giudizio il **Controparte_2** , chiedendo

*“in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da **Parte_3** ai sensi dell'art.348 bis cpc in quanto, fondandosi su tesi palesemente erronee, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;*

*nel merito: respingere l'appello proposto da **Parte_3** in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza 10066/17 in data 9.10.2017 non notificata resa dal Tribunale di*

*Milano confermando che **Parte_3** in persona del legale rappresentante protempore deve pagare la somma ingiunta di euro 6.811,00 oltre interessi dal dovuto al saldo”.*

Ritenuto che l'esame deliberativo delle difese dell'appellante conduce ad escludere una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, considerato che:

- l'appellante non ha preso in esame la ratio decidendi della sentenza né ha contrapposto alla stessa argomentazioni giuridiche specifiche, ma si è limitata a riproporre le medesime questioni già avanzate innanzi al giudice di primo grado e rigettate con argomentazioni chiare, specifiche e dettagliate;
- lamenta l'appellante, quale primo motivo di gravame, l'errata motivazione del Giudice di primo grado in relazione alla violazione di legge per erronea interpretazione e travisamento del contenuto della sentenza n. 7339/2008 resa dal Tribunale di Milano (nel procedimento sub rg 50514/2003 instaurato dai Condomini nei confronti di **Parte_3** violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c, motivazione illogica e contraddittoria, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, omessa applicazione dell'art. 34 cpc, in punto di accertamento su questioni pregiudiziali sulla materia del contendere, quale secondo motivo, la falsa applicazione degli artt. 34 cpc, 2909 cpc, comma 1, Cost., 6 Convenzione EDU, 3, 2, cpa, 5 D.Lvo n. 174/2016, violazione degli effetti preclusivi e/o conformativi derivanti dal giudicato esterno, del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, falsa applicazione degli artt. 99, 101, comma 2, 112 e 115, comma 2 cpc, quale terzo motivo di appello, la falsa applicazione dell'art. 63 D.Lvo 63/1997, Regolamento COSAP, art. 2909 c.c, quale quarto motivo, l'illegittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 130 dpr n. 43/1998;
- come si evince dagli atti di causa, e come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure:

1. Quanto al primo motivo d'appello, parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto dell'accertamento contenuto nel *decisum* 2008 (procedimento rg 50514/2003 instaurato dai Condomini nei confronti di **Parte_3** conclusosi con sentenza n.7339/2008) in ordine al regime dell'area antistante l'esercizio commerciale del bar **Pt_3**

Secondo la tesi dell'appellante, in particolare, sulle aree in questione della Galleria San Babila non sussisterebbe alcuna servitù di pubblico passaggio in favore del **Controparte_2** giacché l'accertamento della situazione sostanziale e della proprietà privata di dette aree -portato dalla sentenza del Tribunale di Milano n.7339/2008, passata in giudicato- conterrebbe anche l'accertamento di inesistenza della pretesa servitù, e ciò in quanto il **Controparte_2** –parte di

quel giudizio (per chiamata in causa ex art.107 c.p.c.) definito con la citata sentenza- non solo non aveva richiesto l'accertamento giudiziale di tale diritto reale, ma non aveva neppure fatto valere la relativa pretesa, preferendo rimanere volontariamente contumace.

Dall'esame di detta sentenza n.7339/2008, in atti (doc. 4 del fascicolo di primo grado), come correttamente rilevato già da codesta Corte d'Appello in altro procedimento sub rg 2315/2015, emerge come il *petitum* di quel giudizio incardinato dai condomini di Via S. Babila n.4/B e 4/C non era l'accertamento della proprietà (pubblica o privata) dell'area in questione, ma era la declaratoria di illegittimità, e conseguente condanna alla rimozione, dei manufatti installati dall'appellante [...]

Parte_5 grave difformità a quanto autorizzatole-, ed in relazione a tale *petitum* l'accertamento della proprietà privata afferiva evidentemente *in primis* alla legittimazione attiva di quei condomini a richiedere ed ottenere detta rimozione in forza e nell'esercizio del diritto dominicale.

Inoltre, come correttamente ribadito dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 10066/17, sentenza appellata nel presente giudizio, nel caso di specie, *“non vi è dubbio che l'area sia di proprietà privata e ciò in quanto non contestato da parte attrice che, anzi, nel proprio atto introduttivo ha affermato che le aree oggetto di occupazione sono di proprietà dei* Parte_6

[...] “

La citata sentenza del Tribunale di Milano n.7339/2008, non confligge e non esclude la sussistenza della servitù di pubblico passaggio che –nel caso in esame- risulta essere innegabile alla luce della sussistenza di tutti i requisiti necessari perché un'area privata possa ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, e cioè, come da giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure: *“l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l'affermazione di un diritto di uso pubblico, ma anche l'ulteriore requisito dell'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù”* (cfr. Cass. sent. n.354 del 2011).

Ancora, come specificato da Giudice di prime cure, *“deve considerarsi del tutto pacifico (oltre che notorio) il fatto che la Galleria San Babila venga utilizzata da una collettività indeterminata di soggetti titolari di un pubblico interesse”*, pur essendo di proprietà del Parte_7 .

I contenuti che Pt_3 ha attribuito alla citata sentenza n.7339/2008 risultano, dunque, errati atteso che in detta sentenza mai è stata messa in discussione l'esistenza della servitù di pubblico passaggio, oggetto, invece, del presente procedimento.

2. Quanto al secondo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'omessa considerazione, da parte del CP_2 CP_2 del principio implicito nell'art. 2909 cc in quanto l'accertamento della

natura privata (e non pubblica, come accertato in sentenza n. 7339/2008 nel procedimento sub rg 50514/2003 instaurato dai Condomini nei confronti di **Parte_3** dell'area rappresenta una verità incompatibile con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata nel presente procedimento, dell'esistenza di un diritto di passaggio, in virtù dell'istituto della *dicatio ad patriam*.

Preliminarmente, si rileva che secondo l'art. 2909 c.c. *“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”*.

Con tale norma, il legislatore ha voluto imporre il provvedimento contenuto nella sentenza del giudice come regola incontestabile dei rapporti tra le parti, conferendo così a questi certezza giuridica.

Si tratta, tuttavia, di una ripetizione del primo motivo d'appello, esposto precedentemente, in quanto il giudicato cui fa riferimento parte appellante relativamente alla sentenza n. 7339/2008, non riguarda l'esistenza della servitù di passo sulla galleria San Babila, ma, ribadendo quanto sopra già esposto, una questione tra privati aventi ad oggetto l'uso delle parti comuni condominiali.

Dalla lettura della sentenza del Giudice di prime cure, risulta evidente che, nel caso in esame, *“dai documenti prodotti è emersa la prova dell'esistenza dei su richiamati requisiti. In particolare: sin dal 1954 la galleria San Babila venne assoggettata sin dalla sua realizzazione a passaggio pubblico (doc. 19 di parte convenuta); i condomini proprietari dell'area per cui è causa, nel giudizio definito dal Tribunale di Milano, con la sentenza 7339/2008 (doc. 2 di parte attrice), hanno espressamente affermato che detta area era sottoposta a servitù di pubblico passaggio (doc. 22 dell'ente convenuto); inoltre, la dichiarazione dell' **CP_5** (doc. n. 21 fascicolo di parte convenuta) afferma : “in base al contratto di servizio stipulato con il Comune ad **CP_5** è affidata la pulizia delle aree e delle strade destinate ad uso pubblico in via permanente. Questa casistica comprende sottopassi, portici, gallerie, tra cui la Galleria S. Babila. In queste località il servizio consiste nella scopatura e nel lavaggio delle superfici calpestabili con l'impiego di lavaspazzatrici meccaniche o altri sistemi idonei.”*

Conseguentemente a ciò, il Giudice di prime cure rileva che *“in tale situazione, cioè, posto che la strada era stata assoggettata a servitù di pubblico passaggio (dovendosi anche considerare, in senso negativo, che ove così non fosse non troverebbero alcuna giustificazione gli interventi del **CP_2** relativi alla manutenzione della stessa, cfr. doc. 21 del **Controparte_2**), il passaggio sulla stessa da parte dei membri della collettività (passaggio non contestato) veniva esercitato quale uti cives, cioè, quale titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non, invece, uti singuli, cioè, quali soggetti che si trovavano in una posizione qualificata rispetto alla stessa strada”*.

Dalla lettura della sentenza del Giudice di prime cure si evince chiaramente come *“tali circostanze valgono a provare che in Galleria San Babila, sussiste effettivo il libero e pubblico passaggio ripetuto ad oltre cinquant'anni”* e ciò risulta perfettamente compatibile con il diritto di proprietà in capo ai Condomini della Galleria San Babila.

3. Quanto al terzo motivo di appello, parte appellante lamenta che nel caso di specie mancherebbero i presupposti per esigere il pagamento della *Org_2*

Nel caso di specie, in merito alla natura del canone per cui è causa, come già correttamente ribadito dal Giudice di prime cure *“il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (...)”* (in tal senso Cass. 6/8/2009 n. 18037).

L'art. 2 comma 4, del Regolamento COSAP del Comune di Milano prevede che: *“sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggetta a servitù di passaggio”*.

Nel caso di specie non vi è dubbio che l'area pur di proprietà privata (come accertato con la sentenza n. 7339/2008, passata in giudicato), su cui insiste servitù di passaggio in favore del Comune di Milano, sia utilizzata da *Parte_3*

Pertanto le censure di *Parte_3* in merito alla mancanza di presupposti ai fini del pagamento del canone Cosap, come già il Giudice di prime cure aveva correttamente rilevato, appaiono infondate.

4. Sul quarto motivo d'appello, parte appellante lamenta che la potestà impositiva esercitata dal *CP_2* e l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale sarebbero illegittimi atteso che, quand'anche esistesse la servitù di uso pubblico, questo –a suo dire– non legittimerebbe tale pretesa impositiva del *CP_2* a detta di parte appellante, infatti, il sistema di riscossione coattiva delle entrate di cui si è avvalso il *CP_2* di Milano sarebbe stato abrogato dall'art. 130 del DPR n. 43/1988, in vigore dal 01.01.1990 che ha sostituito il vecchio sistema di riscossione dei tributi in quanto attualmente avviene mediante ruolo.

Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta evidente che, affermata la certa esistenza della servitù di pubblico passaggio, *“il canone COSAP è stato legittimamente richiesto dal Comune di Milano. Questo, infatti, ha agito in forza di norme regolamentari”*; correttamente il Giudice di

prime cure ha evidenziato come, *“il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è collegato a tariffe riportate nell’allegato al Regolamento approvato con delibera comunale n. 11/2000, e successive modifiche ed integrazioni ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.lgs n. 446/97 sopra citato e con la delibera consiliare 11/2000 (documento 6 parte convenuta) ha adottato il regolamento per l’applicazione del canone COSAP con decorrenza 1.1.2000”*.

- Nel contesto sopra descritto, l’appello proposto non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.;
- conseguentemente, l’appellante va condannato a rifondere alla parte appellata che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello stato processuale (fase introduttiva dell’appello) nel quale la pronuncia interviene e, comunque, dei parametri e criteri di legge (regolamento di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014 e D.M.8.3.2018 n. 37), si liquidano come in dispositivo;
- sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, co.1quater, DPR 115/2002.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile l’appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.;
- condanna l’appellante a rifondere al Controparte_2 le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di 25000,00, oltre oneri di legge;
- condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis e co. 1, quater D.P.R. 115/2002.

Si comunichi.

Milano, 14/11/2018

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Maria Elena Catalano

Il Presidente

Dott. Massimo Meroni